

集体建设用地向宅基地的地性转换

耿 卓^{*}

内容提要：法律要求和实践需求提出了宅基地和集体建设用地之间地性转换的改革命题。集体建设用地向宅基地的地性转换，是突破制度制约和摆脱观念羁绊的改革举措，具有重要的政策价值和实践意义。地性转换有其伦理基础和历史基础，集体建设用地和宅基地的规范构造亦为地性转换奠定了制度基础。从实践发展来看，地性转换具有间接性、模糊性和非正式性的特点，可以划分为自发自为阶段、严格管制阶段、“三块地”改革阶段和新一轮改革阶段，其中蕴含了值得挖掘利用的制度资源，可以为未来发展提供启发和参考。地性转换应坚持底线思维，坚持以人为本，坚持节约集约利用集体建设用地，尊重基层实践，突出分类施策，注重改革协同。我们可以从地性转换的决定主体、内容和程序等方面明晰其制度要点，为实现农民户有所居的改革目标提供理论方案。

关键词：土地管理法 户有所居 宅基地 集体建设用地 地性转换

我国民法典的颁布实施是法治建设中新的里程碑，与亿万人民群众的福祉、经济社会的基本秩序和可持续发展息息相关，关系到治理体系和治理能力的现代化。以党的十八届三中全会提出的农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度（简称“三块地”）改革为主体的土地制度改革进展不一，政策和经验的法律转化尚未彻底完成。在民法典颁布实施这一时代背景下，“三块地”改革及其法治化的继续推进必须置于民法典的制度环境中。民法典物权编在回应经济社会发展需求、落实土地制度改革等方面取得了重要进步，但受限于土地制度改革的复杂性和改革实践的发展进程，对宅基地和集体建设用地的制度供给仍显不足，这些改革之间的内在逻辑和价值体系关联仍有待加强。“三块地”改革随着2019年第三次修正的土地管理法的颁布而告一段落，土地征收和集体经营性建设用地入市改革步入实施细化阶段，宅基地制度改革继续试点探索。包括宅基地在内的农村土地制度改革必须尊重、贯彻和弘扬民法典的时代精神和制度要求，着力于“三块地”改革的协同联动，发挥改革的加乘效应。

实践中，农村村民（农民）在废弃的乡镇企业旧场地上建房、整理闲置的宅基地兴建集体物业的情况多有发生，而在“三块地”改革试点中，农民集体在经济利益的刺激下整理闲置

^{*} 广东外语外贸大学土地法制研究院教授。

本文为国家哲学社会科学基金重大项目“新时代中国特色土地管理法律制度完善研究”（18ZDA151）的阶段性成果。

宅基地、集约节约利用宅基地的热情高涨。^{〔1〕}随着“三块地”改革的深入推进,集体建设用地入市与宅基地制度改革的协同联动也日益受到重视,但相关研究主要集中在宅基地向集体建设用地的地性转换,^{〔2〕}对从集体建设用地向宅基地的反向地性转换(本文以下所称“地性转换”,专指此种地性转换),^{〔3〕}却未给予应有的关注。^{〔4〕}在供地形势日益紧张的背景下,以多种形式实现“一户一宅”住房保障政策的主张成为各界共识,^{〔5〕}而对其具体实现形式的探讨尚待加强。我们需要对宅基地制度进行更加系统深入动态的研究,为立法完善和法律实施提供理论支撑,为全面有效实现农民户有所居提供可行的制度方案。

一、地性转换提出的背景与意义

集体建设用地^{〔6〕}向宅基地的地性转换,就是在符合一定条件和遵循特定程序下,集体建设用地改变原用途用作建造住宅以供农村村民居住的情形。地性转换是基于不同价值目标衡量而为之新选择,是对两种不同用途、不同制度构造的建设用地的重新调整,是土地用途严格管制和国土空间规划制度硬约束下的弹性变通。地性转换不是也无法通过简单的逻辑推演和理论演绎即可实现,而是受到多重制约,其提出有着深刻的社会背景,具有重要的政策价值和实践意义。

(一) 社会背景

1. 制度约束

人的行为都是社会环境的产物,受到制度等诸多因素的约束,土地利用行为更是如此。不仅土地用途从农转为非农的建设利用需要严格遵守土地用途管制规定,符合土地利用规划和城乡规划的总体要求,即使是已被用于非农建设的土地的具体用途变更,也受到上述管制和规

-
- 〔1〕 参见耿卓、孙聪聪:《乡村振兴用地难的理论表达与法治破解之道》,《求是学刊》2020年第5期,第4页。
- 〔2〕 参见温世扬、梅维佳:《宅基地“三权分置”的法律意蕴与制度实现》,《法学》2018年第9期,第53页;杨燕玲:《集体土地建共有产权住房与市场制度的衔接研究》,《农村经济》2020年第10期,第95页;巩前文、穆向丽:《闲置宅基地转变为集体经营性建设用地入市的政策思考》,《农村经营管理》2020年第4期,第18页以下。
- 〔3〕 “地性转换”是本文对社会现象和法律现象的描述和概括。部分学者把我国土地公有和二元所有制下集体土地转为国有土地的土地所有权变动现象概括为转换,在术语表达上既有转换、转化的提法,也有概括国有化、整体转权等提法。参见陈甦:《城市化过程中集体土地的概括国有化》,《法学研究》2000年第3期,第108页;张忠野:《简论我国土地转换法律制度的完善》,《法制与社会发展》2003年第4期,第141页;宋志红:《城市化进程中集体土地的整体转权》,《国家行政学院学报》2010年第4期,第14页。简言之,这种地性转换主要是所有权变动的另一种表达,而非一种实质性、规范性的概念。而本文论及的集体建设用地与宅基地互相转换地性,是指农村土地具体用途的变化,既有权利的变动,也有权利基础不变时的土地具体用途变动,还往往伴有集体所有权主体行使权利、集体成员享有权益的复杂现象,因此为研究便利,本文将之概括为“地性转换”。
- 〔4〕 在笔者的阅读范围内,仅见到一篇评论明确提及“探索构建公益性建设用地、集体经营性建设用地转为宅基地使用权的有效通道”。参见袁威:《宅基地制度改革要处理好四个关系》,《学习时报》2020年8月12日第A6版。
- 〔5〕 参见陈小君:《宅基地使用权的制度困局与破解之维》,《法学研究》2019年第3期,第48页;高圣平:《宅基地制度改革政策的演进与走向》,《中国人民大学学报》2019年第1期,第28页以下;刘守英、熊雪锋:《经济结构变革、村庄转型与宅基地制度变迁——四川省泸县宅基地制度改革案例研究》,《中国农村经济》2018年第6期,第18页。这种共识在土地管理法修法中得到体现。
- 〔6〕 在政策文件、理论研究和改革实践中,一般并未专门区分集体建设用地与集体建设用地使用权这两个概念。事实上,无论是集体直接在其所有的土地上开发建设形成的建设用地,还是他人在集体土地上享有的集体建设用地使用权,对地性转换的基本构造没有影响,只是其上设立了集体建设用地使用权的集体建设用地转换为宅基地时,需要先行依法解除该权利负担,故本文未详加区分这两个概念。在土地用途分类中,集体建设用地与宅基地则均属于集体土地,只是具体建设用途不同;两者又均为乡村建设用地的下位概念,此处的乡村建设用地是指分布在乡村的建设用地,仅是地理意义上的概念,不以集体所有为必要。

划的限制。前者所述的限制和约束,更容易被理解和接受;而对于后者,人们往往忽视甚至不以为然。对此,我们可以结合法律制度加以揭示。

从法律规定来看,1986年土地管理法初步建立了二元的建设用地制度。其第36条和第39条规定,无论是全民所有制企业、城市集体所有制企业与农业集体经济组织共同投资兴办的联营企业使用集体土地,还是乡(镇)村企业建设需要使用集体土地,都由县级以上地方人民政府批准;乡(镇)村企业的土地利用受到他们所处行业 and 经营规模的影响。1998年土地管理法第20条首次确立了土地用途管制制度,要求县级、乡(镇)土地利用总体规划划分土地利用区,明确土地用途,乡(镇)土地利用总体规划还应根据土地使用条件确定每一块土地的用途,并予以公告。这一规定沿用至今。就集体建设用地制度而言,1988年土地管理法修正的主要内容是删除了原第2条第2款“任何单位和个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地”中的“出租”,并新增加一款:“国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让的具体办法,由国务院另行规定。”随后,国家只就国有土地使用权转让出台了具体办法,^[7]集体土地的使用权转让被搁置,甚至连这一新增的授权性规定在1998年土地管理法修订中都被删除了。只有通过“三块地”改革并修改土地管理法,集体建设用地的制度生成和具体用途多样化才得以实现。我国土地法律制度的强烈管制色彩和“法有规定方可为”的特点,可见一斑。

2. 观念羁绊

土地在政治、经济和社会中无可替代的重要地位决定了国家的慎重对待,管制也呈现出制度化、严密化的趋势,社会观念因此得以形塑。土地的财产性质并不纯粹,受到情感、观念和制度等诸多因素的深刻影响,管制等对自由利用的限制深嵌到相关主体的土地利用观念之中。就宅基地而言,从申请宅基地到获批,从建房的规划、许可到改建翻建审批,从危房改造到农房商业利用直至所谓“小产权房”,无不受到中央和地方各类规范性文件的规制。就集体建设用地而言,除了用途管制外,入市的客体从存量扩大到增量,入市的方式从被动单一扩展到主动多元,入市具体用途得以进一步明确具体,以及集体建设用地的来源和指标,都是冲破重重障碍才成为正式制度的,而且从“纸面上”落实到“行动中”也同样如此。^[8]

总的来看,一方面,土地制度领域的规划管制等约束性观念非常强大;另一方面,历史传统和制度约束下的私法观念却相当淡薄。私法领域的意思自治、“法无禁止皆自由”以及财产权自由行使观念,虽然随着经济社会发展和法治建设的推进而大大增强,但社会民众特别是公权力部门的观念意识并没有同步更新,而且私法观念在不同领域的落实程度不一。在土地领域,“率土之滨,莫非王土”的历史传统和化私为公的社会主义改造,塑造了整个社会对土地制度、土地利用和土地权利的认知并构成社会主流观念的基础。集体土地所有权的变动即为著例。农民集体可以决定其土地所有权变动如归并到其他集体,这既符合法理,又有实践做法支撑,但源于宪法的坚持集体所有制和土地国有的观念,使个别地方的集体土地同样基于农民集

[7] 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》于1990年5月19日颁布施行。此外,1989年7月22日国务院发布《关于出让国有土地使用权批准权限的通知》(国发〔1989〕49号),以规范国有土地使用权有偿出让和转让的审批权行使。

[8] 例如,广东省东莞市《关于进一步规范农民住房建设的通知》(《东莞日报》2020年1月8日第B4版),暂停全市以农民宅基地个人或联户建设农民安居房的审批工作,并严厉打击农民安居房违建行为。如此规定虽有其必要性,但也在一定意义上说明土地利用行为随时可能受到管制的现实。

体决定而自愿转为国有土地和两种土地互换等做法,却只能在试点地区运行或法外运行。

(二) 现实意义

1. 政策意义

以人民为中心的发展思想是我们的行动指南,也是农村土地制度变革的行动指南。在农村土地利用方面,地性转换也是贯彻以人民为中心发展思想的具体而重要的体现,是根据特定地区具体发展情势实施乡村振兴战略的客观需要。

贯彻以人民为中心的发展思想和新发展理念,要求回应、满足人民的基本生活需要,要求政策制定和制度实施赋予人民权利并保障人民权利的实现。住有所居是人民的基本需求和基本权利,在住房社会保障尚未覆盖的广大农村尤其如此。无论是宅基地灭失后的原宅基地使用权人,还是从未实际独立享有宅基地的农民,都应得到保障。在部分地区,存在集体建设用地的低效利用甚至闲置与农民长期无宅基地可分的矛盾。^[9]而且部分宅基地面积严重超标与闲置的现象,^[10]遮蔽了部分农民无宅基地可分的实际困难。因此,允许集体建设用地向宅基地转换以增加宅基地供应渠道的方案,是贯彻以人民为中心发展思想保障农民住有所居的具体体现。

乡村振兴战略的全面实施给我们提出了新要求。这一战略要求我们创新理论,为宅基地“三权分置”改革提供支撑,深化宅基地“三权分置”特别是农户资格权的法理研究,切实保障宅基地农户资格权,探索其具体实现形式。资格权主要是保障农民住有所居。^[11]探索打通宅基地与集体建设用地之间地性转换的具体机制,既是“三块地”改革的方向性要求和下一步改革的重点,也是保障农民住有所居的重要途径。

2. 现实价值

地性转换是回应社会现实和实践发展的需要,是推进土地改革协同联动的内在要求。乡村振兴战略的实施是一个长期的过程,需要分阶段、分层次、分步骤实现,既要面向未来解决发展中的问题,也要正视现实、解决实际困难。农业农村优先发展不但意味着与非农相比的优先,而且意味着在“三农”内部各需求的满足也有先后之分。就农民居住而言,既存在广大农民的居住条件和环境进一步改善的问题,也存在部分农民因无法分得宅基地而居无定所或达不到基本标准的问题。遵循农业农村优先发展原则,应优先解决后一类问题,即在宅基地与集体建设用地相互转换时应优先满足宅基地需求。打破二元土地制度壁垒,打开闲置公益性建设用地与集体经营性建设用地、集体建设用地与宅基地的地性转换通道,无疑将为乡村振兴提供不竭动力。^[12]

[9] 2016 年度全国土地变更调查数据显示,新增建设用地主要集中在中西部,而东部地区建设用地包括宅基地在内的农村建设用地基本没有增加。参见《2016 年度全国土地变更调查结果公布》, http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/21/content_5212349.htm, 2021 年 2 月 22 日最后访问。“城乡建设仍以外延扩张的发展模式为主,2018 年全国人均城镇工矿建设用地 146 平方米、人均农村居民点用地 317 平方米,超过国家标准上限。”陆昊:《全面提高资源利用效率》,《人民日报》2021 年 1 月 15 日第 9 版。

[10] “目前全国亿亩村庄建设用地中,‘空心村’内老宅基地闲置面积约占 10%—15%;另一方面由于现有体制下农民没有形成合法的住房市场,新建家庭无法通过正常的市场交易获取农民住房,为了满足新成立家庭居住的住房需求,基层政府和社区组织不得不给新增家庭安排宅基地,导致村庄宅基地面积不断扩大。”汪晖、陶然:《中国土地制度改革:难点、突破与政策组合》,商务印书馆 2015 年版,第 107 页。各地的闲置情况不一,但均有一定比例。参见王良健、吴佳灏:《基于农户视角的宅基地空心化影响因素研究》,《地理研究》2019 年第 9 期,第 20 页以下;刘兆军、王琪、杜国明:《东北粮食主产区村庄宅基地空心化空间分异及其影响因素分析——以黑龙江省克山县为例》,《中国土地科学》2020 年第 6 期,第 96 页以下。

[11] 参见韩俊主编:《实施乡村振兴战略五十题》,人民出版社 2018 年版,第 243 页以下。

[12] 参见叶兴庆等:《农业农村改革若干重大问题研究》,中国发展出版社 2018 年版,第 30 页。

因此,无论是从宏观的国家治理还是从微观的私权构造来看,满足农民居住需求的制度设计都具有重大现实意义。

随着城乡社会结构变化、城乡空间结构演化和经济体制改革深化,现行宅基地制度存在的问题和面临的挑战日益突出,落实宅基地“一户一宅”的制度规定更加困难,^[13]农村地区用地供需矛盾尖锐,新增宅基地取得愈发困难,宅基地基本无地可供。^[14]部分农户的宅基地使用权处于“冷冻”状态,受到了现实土地资源不足的硬约束。^[15]广东外语外贸大学土地法制研究院课题组在珠三角地区的专项土地调查结果显示,各地在1998年土地管理法修订前后至今基本没有审批过新的宅基地,整整一代人只能自谋出路,居住条件长期难以改善。^[16]

综上所述,宅基地供应存在结构性、区域性问题,实行集体建设用地向宅基地的地性转换,是满足农民住有所居、开启美好生活新篇章的顺势之为,是精准理念的生动体现,是供给侧的有效改革,因而有着重要的政策意义和深刻的现实价值。

二、地性转换的三重基础

(一) 地性转换的伦理基础

根据马克思主义理论,社会主义制度下“真正的平等不是以同样的标准对待每个人,而是对每个人的不同需要给予同等的关注”。^[17]就我国农村宅基地制度而言,既有形式平等上的要求,即“以同样的标准对待每个人”,所有的农民理应得到同等对待,农民集体应为农民提供同等的居住保障;也有实质平等上的要求,即“对每个人的不同需要给予同等的关注”,无论是分家析产前的农户还是成家立业后需另立门户的农民,在保障一户一宅或住有所居方面都应得到同等关注。可见,地性转换既是形式正义的体现,亦符合实质正义的要求。德国哲学家赫费提出的交换正义及其对政治正义的廓清与重申,^[18]超越了纯粹经济意义上的交换和交往关系所构建的公平,从国家伦理角度保障了个体的自由和平等的实现。^[19]地性转换也体现了赫费的交换正义及其对个体公平的保障。

赫费的交换正义理论是对罗尔斯正义论的更新和补充,它解释了分配正义中所分配之物

[13] 2019年土地管理法第62条第6款为新增条款,规定“鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅”,该款限制了集体经济组织基于第66条所享有的收回权的适用范围。2018年农村土地承包法直接删除了全家迁入设区的市、转为非农业户口的承包方应当交回承包地的义务和发包方可以收回承包地的权力。与这两者不同的是,集体建设用地因闲置被集体收回的制度架构在修法中得到维持。因此,可以激活收回制度,提高土地利用效率,增加转换为宅基地的集体建设用地来源。

[14] 参见前引[11],韩俊主编书,第241页以下;宋志红:《中国农村土地制度改革研究:思路、难点与制度建设》,中国人民大学出版社2017年版,第279页;韩松:《论宅基地分配政策和分配制度改革》,《政法论丛》2021年第1期,第70页。

[15] 参见宋志红:《宅基地资格权:内涵、实践探索与制度构建》,《法学评论》2021年第1期,第88页。

[16] 在其他地方也是如此。“由于土地资源紧张,上海已经10余年未分配宅基地。”李凤章:《宅基地资格权的判定和实现——以上海实践为基础的考察》,《广东社会科学》2019年第1期,第231页以下。

[17] [英]特里·伊格尔顿:《马克思为什么是对的》,李杨等译,新星出版社2011年版,第107页。

[18] “本书试图建立一种更深刻可靠的与功利主义相反的模式……对法和国家采取既非绝对承认同时又相对拒绝的做法”,重建政治的正义性即合法性;“政治合法性中至关重要的正义不是分配性正义,而是交换性正义”。[德]奥特弗利德·赫费:《政治的正义性——法和国家的批判哲学之基础》,庞学铨、李张林译,上海译文出版社2005年版,第4页以下,第272页。

[19] 参见张晓萌:《平等与自由的正当性之争——对G. A. 科恩与罗伯特·诺奇克论争的批判性解读》,《当代中国价值研究》2017年第2期,第41页。

的来源以及国家强制权力的根据。该理论对传统交换正义在对象领域和主体上作了扩展：交换既可以发生在不同的对象领域，除了交换物质外，还交换服务甚至包括一些理念性事物，如安全、权力和认可，特别是自由和自我实现的机会；也可以发生在不同主体之间，在群体之间的交换产生制度的正义性，在个体、群体与国家之间的交换则产生政治的正义性。^[20] 国家与人民之间只有首先满足了赫费的交换正义，人民出于在法理上可以被证成的依据与国家发生交换，国家才可以占有某些资源。这一分析同样适用于农民与农民集体之间的关系。集体建设用地向宅基地的地性转换，本质上可视为土地价值在共同体中个体间的分配，可理解为对共同体与个体之间交换正义的回归或某种程度的实现。集体土地所有制的形成历史充分说明了这一点，下文将专门展开。事实上，这也是化解我国集体土地权益分配中利益冲突的应对之道。^[21]

不仅如此，詹姆斯·塔利基于洛克财产理论提出的“包容性权利—排他性权利”的分析框架，^[22] 也为地性转换奠定了基础。塔利认为，在洛克那里，存在两种具有内在关联的权利概念：一是包容性权利，即每个人都配得的、所有人都共同享有的权利；一是排他性权利，针对的是某人自己所有之物的权利，即通常意义上的个人财产权。排他性权利对包容性权利的个体化，不仅没有消解对共有之物的财产权，反而实现了对共有之物的财产权，因为排他性权利的主体仍旧是“共有物的一名承租者”。这种理论试图超越“公有一私有”的二元对立框架，提供一种对财产权的全新理解。我国的土地财产权就呈现出一种权利的“共有”维度和“个体”维度的二维构造。其中，排他性财产权利关注的是“物尽其用”的土地资源合理配置和权利保障的个体维度，而包容性的土地公有则关注人的保障和发展，即每个个体都有资格共享土地从而在物质条件上实现公平。类比土地国家所有来看，集体所有同样是一种包容性的权利，每个人对它都有一种资格，即作为排他性权利的个人土地财产权实际上是土地集体所有这种包容性权利的最终实现和个体化的结果，这也正是土地集体所有的公共性体现。在此意义上，地性转换实质上就是集体所有建设用地这一包容性权利转换为个体化的排他性的宅基地（使用权）。

（二）地性转换的历史基础

1949年以来，我国的土地制度在诸多因素影响下演变出多重的二元性：一是生产资料与生活资料社会主义改造的二元路径，二是全民所有制和集体所有制的二元构造，三是城乡分野的二元形态，四是市场化与福利性的二元特点。包括宅基地制度在内的农村土地制度，充分体现出这些二元性。

马克思有关生产资料与生活资料的二分，对我国1949年以来的经济、社会和法律发展包括社会主义改造路径选择产生了决定性影响。在农业和土地领域，社会主义改造的核心在于集体化，集体化的根本在于实现生产资料主要是土地的公有制。^[23] 农村土地的集体化，是在“耕者有其田”思想的指导下，率先从农地（耕地）开始的，并扩展至牲畜等农业生产工具。在社会主义改造过程中，基于房地一体的特点，国家遵循了地随房走原则。1954年宪法第11

[20] 参见张海燕、高靖生：《当代正义论证范式的一种转型——奥特弗利德·赫费的交换正义性评述》，《国外社会科学》2007年第1期，第70页以下；庞学铨：《赫费的政治正义性理论——赫费政治伦理学的主要理论贡献》，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》2017年第4期，第24页以下。

[21] 参见陈菲菲、肖泽晨：《我国农村土地权益分配上的利益冲突与平衡》，《江苏社会科学》2020年第3期，第155页。

[22] 参见刘小平：《土地财产权的二维构造——一种从现实出发的理论解释方案》，《法制与社会发展》2017年第6期，第126页以下。

[23] 参见胡震：《农村宅基地产权法律表达的70年变迁（1949—2019）》，《中国农业大学学报（社会科学版）》2019年第6期，第67页以下。

条规定,房屋属于农民的生活资料。结合前述原则,我们可以推论,房屋下地基(宅基地)的属性只有与房屋属性保持一致,才能落实宪法规定,因此农民的房屋及其地基(宅基地)被视为生活资料,由农民继续享有所有权并得到保护。

但是,土地公有制可以说是党的政策和社会主义改造的基本要求,也是宪法规定的基本预设,因而即使是作为生活资料的宅基地也难以例外。事实上,这也是制度演变的逻辑结果。随着作为生产资料的农地的集体化,农民原来将自家农地转变为宅基地而得以满足的建房需求只能由集体所有权来满足,如果宅基地仍作为生活资料由农民享有所有权,就会出现因生产资料和生活资料相互转换而带来的集体所有权向私人所有权转换的困境,宅基地的公有化、集体所有也就势在必行了。《高级农业生产合作社示范章程》(1956年6月30日,第一届全国人民代表大会第三次会议通过)第16条第2款豁免了房屋地基的入社,并规定由合作社统筹解决社员新修房屋所用地基问题,已对大量新增农村人口的建房需求有所回应。《农村人民公社工作条例修正草案》(1962年9月27日,中国共产党第八届中央委员会第十次全体会议通过)第45条第4款作了进一步规定:国家和人民公社的各级组织除了对社员修建住宅给以可能的帮助外,生产队还应统一规划社员新建房屋的地点。为稳定农民情绪、回应农民诉求,1963年中共中央还发出《关于各地对社员宅基地问题作一些补充规定的通知》,进一步明确社员对宅基地“长期使用,长期不变”的政策,且“社员新建住宅占地无论是否耕地,一律不收地价”。也就是说,集体成为宅基地所有权人,哪怕仅仅是名义上的,也要负担为集体成员无偿分配宅基地的责任。^[24]

生存在我国农民的生活中是第一位的,作为农村土地集体化的产物,自留地的存在就是为了保障农民的基本生存。在农村生产力尚不发达的情况下,如果没有自留地,农民就在一定程度上失去了抵御灾荒的能力,甚至在普通时期也会生活困窘。宅基地制度的形成也遵循了相同的逻辑,具有类似的原因。^[25]因此,农用地转换为宅基地、集体建设用地转换为宅基地等宅基地供应的各种途径,都是这一历史逻辑下的产物,都有其正当性。

(三) 地性转换的制度基础

无论是集体建设用地还是宅基地,从根本上说都服务于集体成员利益。集体建设用地入市是集体收益由集体成员共享,而宅基地则是由单个或若干集体成员独享,在表面上似乎存在利益失衡的问题。但事实上,地性转换作为面向不特定主体的制度安排,不仅有利于当下的无宅基地农民,而且也有利于将来所有因无地可供而居住保障不足的村民。换言之,有宅基地者与无宅基地者只是在分得宅基地的时间先后上有所不同而已,没有利益失衡之说,自然无须平衡利益。即使个别有宅基地的村民的预期利益因此受损,相较于无宅基地村民的居住保障利益,也有位阶上的先后之别。集体建设用地和宅基地都服务于农民集体(实质是其成员),主要区别在于受益人的群体性和单一性。不过,这仅仅是就地性转换后实际分给某一村民而言的。制度规则的抽象性和适用的普遍性,使得享有这一权益的主体并不特定,而可能是该集体任一成员的后代、亲属等相关者,从而与集体经营性建设用地的受益人具有相似性。

从规范层面看,民法典第364条、土地管理法第62条第2款和乡村振兴促进法第67条为地性转换提供了制度基础。民法典第364条是对宅基地灭失及重新分配的规定,直接继承了原物权法第154条,只是对“重新分配宅基地”强调了“依法”。鉴于民法典基本没有吸收宅基

[24] 参见田传浩:《宅基地是如何被集体化的》,《中国农村经济》2020年第11期,第43页。

[25] 参见李勤通:《农村集体土地制度的宪法解释》,《北方法学》2015年第6期,第147页以下。

地制度的改革成果，仍然维持了通过转引性规定由土地管理法规范宅基地使用权的格局，强调“依法”一方面在于原则上要求重新分配宅基地应合法；另一方面，结合第363条的规定，可以发现其指向了“土地管理的法律和国家有关规定”，明确并划定了所依据法律的范围包括“国家有关规定”，使得参照执行中央政策文件成为可能。民法典第364条主要是对宅基地灭失及其法律后果的规定。宅基地灭失，往往并非指地块在物理上彻底不存在，而主要是指从用途上看，地震、山体滑坡等客观原因导致宅基地无法继续由集体成员占有、使用。显然，宅基地灭失意味着宅基地使用权的标的物灭失，其权能和用途均无法继续实现，必然导致宅基地使用权被迫终止（即消灭），原宅基地使用权人势必居无着落。此外，推进乡村振兴而引进人才等其他情形，对宅基地的需求亦在所难免。根据该条规定，农民集体负有重新分配宅基地给原宅基地使用权人的法定义务，这也是宅基地所有权人主动落实宅基地成员资格利益的途径。^{〔26〕}乡村振兴促进法第67条在土地节约集约利用原则下，提出完善农村新增建设用地保障机制，盘活农村存量建设用地，以满足乡村产业、公共服务设施和农民住宅用地的合理需求，体现出该条所在“扶持措施”章的立法意旨。

不仅如此，从宪法学角度看，从指向共同体价值的、集体性权利的集体建设用地转换为保障个体尊严与生活的基本权利的宅基地，也意味着权利背后侧重实现的法益发生了改变。这种地性转换的宪法规范基础可以通过体系解释和目的解释加以呈现。2004年宪法修正时，将第13条中的“公民的合法的……所有权”改为“公民合法的私有财产”，是一种典型的宪法委托立法者形成基本权利的保护范围，因此只要有法律依据，建设用地转换为宅基地意味着通过立法形成将集体建设用地具体化为公民的一种合法财产形态（宅基地）。在民法典和土地管理法留出规范空间的情况下，自然可以在宪法上确证其地位。

总之，地性转换并非简单的逻辑推演，更非闭门造车的理论空想，而是有其内在的观念基础、深厚的历史基础和坚实的制度基础。事实上，地性转换不仅仅是一种对社会实践积极回应的纯粹的理论设想，而且在经济社会发展中有诸多因应各种实践需求的探索和尝试，尽管这些探索和尝试尚处于自发、零散、隐而不彰的状态。

三、地性转换的自发探索

地性转换在我国并没有进行自觉、直接明确和系统的改革或探索。不过，在改革开放以来的农村土地制度改革历程中，在诸多改革试点和丰富的基层实践探索中，以及在中央农村土地制度改革政策和立法中，都蕴含了大量相关内容，为地性转换提供了有益的经验 and 参考。地性转换呈现出从自发自为到严格管制的演变特点，蕴含了向有序自由发展的趋势。

（一）自发自为阶段

这一阶段主要是改革开放后、从1986年土地管理法制定到1998年土地管理法修订的时期。由于土地管理基本制度处于起步阶段，还比较粗疏，因此宅基地和集体建设用地在管理上并未作明确细致的区分，两种土地之间的互相转用时有发生。我们在珠三角地区调研发现，存量乡村建设用地的具体利用情形比较多元：既有圈占超面积宅基地进行初级工商业开发的情况，又有在通过以租代售、代征等途径取得的集体建设用地上建房用于自身或员工居住的情

〔26〕 参见前引〔5〕，陈小君文，第48页。

况。反映了国土部门在集体建设用地流转上意图的安徽芜湖试点方案,同样包含乡村企业、公共设施、公益事业、个体私营企业和“农村村民建住宅等可使用集体建设用地”的内容。^[27]实践中建设农民公寓的探索就是一个典型。农民公寓是指为农民统一建造、集体居住的单元农民公寓式住宅,最早始于20世纪90年代初的广东,在城镇化开发较早的江浙地区也大量存在。^[28]部分地区还进行了不以有无宅基地为限定条件的满足居住需求的实践探索。实践中的土地征收补偿安置模式、旧村整治改造模式、集体土地上建廉租房模式,各有其适用范围和条件,并不以满足无宅基地农民的居住需求为主要目标,但产生了与地性转换相类似的客观效果。此外,在个别地区还有通过宅基地商品化和土地资本化进行农民自主城市化以解决外来建设者居住问题的探索,^[29]同样蕴含着地性转换的因子。

改革开放伊始,土地利用、规划和管理处于制度建设的起步阶段,问题尚未暴露;各地特别是思想观念开放、竞争意识强而管制又相对薄弱的东南沿海地区大胆探索,形成了包括上述集体建设用地与宅基地互相混用在内的实践做法。这些探索尽管因为不规范而出现不少问题,但无疑为农村土地制度改革开拓了新路,有力地促进了当地经济社会发展。

(二) 严格管制阶段

这一阶段主要是从1998年土地管理法修订到“三块地”改革启动前的时期。1998年土地管理法的修订,直接动因为1997年《中共中央国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发〔1997〕11号,以下简称“通知”)。“通知”在土地制度变迁中影响甚大,明确提出“有条件的地方,提倡相对集中建设公寓式楼房”,“集体土地使用权不得出让,不得用于经营性房地产开发,也不得转让、出租用于非农业建设”。这些要求在1998年修订土地管理法时全部得到落实。

虽然新政策堵住了地性转换的通道甚至对于集体建设用地供给和流转严加限制,关上了“后门”“偏门”,但同时又开了半扇“正门”“前门”:一方面,基于两种土地经济功能的不同,新政策对两者进行区隔,以致固化甚至僵化了两种土地的制度安排;^[30]另一方面,又开展了在集体土地上建廉租房的试点。^[31]尽管政策、法律大幅压缩可能的地性转换空间甚至形

[27] 参见刘守英:《中国土地问题调查——土地权利的底层视角》,北京大学出版社2017年版,第262页以下。

[28] 参见张斌、陈赞绵:《失地农民居住问题引发的思考——以苏州农民公寓发展为例》,《南京工业大学学报(社会科学版)》2004年第3期,第45页。

[29] 参见前引〔27〕,刘守英书,第304页以下。

[30] 1998年土地管理法第63条规定:“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设;但是,符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。”由此,集体土地原则上不得再用于非农建设,只限于存量,且只能被动流转。关于宅基地的规定则主要体现在1998年土地管理法第62条,特别是其第4款明确规定“农村村民出卖、出租住房后,再申请宅基地的,不予批准”。对比1998年修法前的情况,这两条规定对集体建设用地与宅基地的区隔甚为明显。

[31] 参见原国土资源部、住房城乡建设部《关于印发〈利用集体建设用地建设租赁住房试点方案〉的通知》(国土资发〔2017〕100号)。原国土资源部办公厅、住房城乡建设部办公厅《关于沈阳等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函》(国土资厅函〔2018〕63号)和自然资源部办公厅、住房和城乡建设部办公厅《关于福州等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函》(自然资办函〔2019〕57号)审核批准了16个城市的试点方案。利用集体建设用地建租赁住房“与当前正在进行的农村集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革试点的初衷相吻合,与本轮农村土地制度改革的政策导向相一致”。谭荣:《集体建设用地建租赁住房的思考与展望》,《中国土地》2017年第10期,第14页以下。这次试点在全国铺开之前,“2003年以来,上海、广州、北京等地方政府先后启动了集体建设用地建公租房试点”(黄忠、张彦西:《集体土地上建公租房的制度障碍及其突破》,《经济体制改革》2016年第2期,第82页)。此项改革的关键在于“确保农民集体有效参与,实现土地权益,壮大集体经济,助推农民收入持续增加”(陈小君、戴威:《对“集体土地上建公租房”政策的法律思考》,《法律科学》2012年第3期,第160页)。

成了事实上的禁止,但是个别地区如浙江在部分城市城乡接合部进行试点探索,解决农民住房难问题,^[32] 回应他们的强烈需求,体现出务实精神。

(三) “三块地”改革阶段

2013 年 11 月,党的十八届三中全会对“三块地”改革作出重要部署。中央有关部门根据中央部署制定改革试点实施方案,宅基地改革和集体经营性建设用地入市改革从 2015 年 6 月决定的各 15 个试点到 2017 年 11 月扩展至全部 33 个试点。本轮改革于 2019 年底结束。

从宅基地制度改革来看,除了管理体制调整外,主要在扩展农民住房保障形式方面积极探索。(1) 从“一户一宅”向“户有所居”转变。在存量宅基地已经无法满足新增人口居住需求的地区,保障农民居住的方式已经逐渐从最初分配一处宅基地建房,向多户联建、建设住宅小区高层公寓等方式转变。例如,浙江省金华市婺城区白龙桥镇联建农民公寓采用“5 村联建,按资分配”的模式,既解决了村里 60 户农户的住房问题,又增加了各村集体经济收入。^[33] (2) 住房保障方式的多元化发展,探索农村住房保障户有所居的多种实现形式:第一,区分城镇建设用地范围内外不同区域,分类施策,如浙江省义乌市、西安市高陵区、山东省禹城市等。第二,人均耕地少且适合二、三产业发展的乡镇,在农户自愿的基础上实行相对集中统建、多户联建、返乡创业者与当地农民共建等多种模式,如黑龙江省安达市等。总体而言,宅基地制度改革基于稳妥考虑而推进缓慢,力度有限。

集体经营性建设用地入市改革则取得重大进展,但未实现与宅基地改革的协同联动。2017 年原国土资源部和住房城乡建设部《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》完善了之前的做法,从住房供给侧改革入手,拓展集体土地用途,促进集体土地优化配置,对地性转换的实现途径具有较大的启发意义。例如,在“三块地”改革试点的北京市大兴区,2019 年 9 月 15 日,瀛海镇出让 5.56 万平方米的集体建设用地建设共有产权房项目。^[34] 而在适度放活宅基地使用权的改革探索中,四川省的泸县模式通过农户和社会主体共享宅基地使用权,分别通过提供宅基地使用权和资本实现共建共享居住、商住或经营。^[35] 泸县模式的实质是依循集体经营性建设用地入市的做法,在同一宗宅基地上实现了两种用途的共存,也蕴含了地性转换的可能空间。由此可见,集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革只是完成了上半程,艰难的下半程还未实质启动。

(四) 下一轮改革试点的实践动向

在上一轮土地制度改革经验转化为法律后,中央又启动了新一轮宅基地制度改革。2020 年 4 月,中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出:“深化农村宅基地制度改革试点,深入推进建设用地整理,完善城乡建设用地增减挂钩政策,为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。”2020 年 6 月,中央全面深化改革委员会第十四次会议通过《深化农村宅基地制度改革试点方案》;10 月,中央农办、农业农村部批复全国 104 个县(市、区)和 3 个设区市为新一轮农村宅基地制度改革试点地区;11 月,农业农村部

[32] 参见《提前拆迁:推进规划控制区农房解困新模式》,《浙江国土资源》2014 年第 1 期,第 10 页。

[33] 参见周垚、杨晓峰:《金华白龙桥联建农民公寓,助力美好生活》,浙江新闻网, https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/jhnews/202102/t20210201_22055889.shtml, 2021 年 2 月 1 日最后访问。

[34] 参见田国宝:《北京诞生全国首个可售集体建设用地住宅项目》,经济观察网, <http://www.eeo.com.cn/2019/0916/365696.shtml>, 2021 年 2 月 28 日最后访问。

[35] 参见前引[5],陈小君文,第 48 页。

办公厅印发《农村宅基地制度改革试点工作指引》。从新闻报道看,各试点地区根据中央统一部署和批复方案积极开展宅基地制度改革试点工作。新一轮宅基地制度改革正从文本走向实践。

1. 规范文本评析

改革政策以处理好农民和土地的关系为主线,以保障农民基本居住权为前提,以完善农村宅基地制度体系为重点,坚持先立后破、稳慎推进,探索宅基地“三权分置”。除了探索宅基地资格权的认定办法和多种实现形式外,本轮改革还要“完善不同区域农民户有所居的多种保障方式”。^[36]

以上改革任务要求在乡村振兴促进法第67条第1款规定中也有反映。根据该规定,结合2020年中央一号文件中中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,^[37]农民住宅用地也在农村新增建设用地保障的对象之列,因而无宅基地农民获批宅基地的要求显然合理合法。

2. 试点实践总结

试点地区主要是从宅基地的供求角度着手的。从需求来看,“随着城镇边界拓展与农村人口转移,在宅基地管理中出现了取得困难”等问题;^[38]在乡村振兴过程中,乡贤回归的住房保障条件和形式也亟待明确。^[39]浙江省德清县将宅基地资格权认定事项纳入宅基地管理章程,建立“途径多元、自主选择、城乡联动”的资格权保障体系,探索宅基地资格权的多元化保障机制。^[40]江苏省常州市武进区正全面推进农民自建房建设,9个镇已规划35个农民自建房。^[41]在新一轮改革中,“浏阳在城乡合作建房等方面的试点经验被成功采纳”。^[42]从供给来看,主要是大力整治“一户多宅”“建新不拆旧”等问题,以有效增加宅基地用地空间,满足符合分配条件的农户的建房需求,确保户有所居。^[43]

(五) 总结与展望

纵览我国农村土地制度改革史,实事求是、解决现实问题、满足实践需求、助推人和乡村的发展,是始终不变的主线,形成了改革的原则、要求、策略和方法。详言之,一是改革的原则,承认实践探索,注意顶层设计与自发探索相结合;二是改革的要求,坚持依法改革,既改革旧的僵化的制度规则,又坚持重大改革于法有据;三是改革的策略,有序稳妥推进,既坚持改革方向不动摇,又突出重点,因地制宜把握改革的节奏和方式;四是改革的方法,运用试点改革方法,通过挑选改革试点,探索突破推进,再总结经验上升为法律,全国推行。

[36] 参见农业农村部办公厅《农村宅基地制度改革试点工作指引》(农办经〔2020〕8号)。

[37] 即新编县乡级国土空间规划应安排不少于10%的建设用地指标,重点保障乡村产业发展用地。省级制定土地利用年度计划时,应安排至少5%新增建设用地指标保障乡村重点产业和项目用地。

[38] 《斗门进入全国新一轮农村宅基地制度改革试点》,珠海市斗门区人民政府网站, http://www.doumen.gov.cn/zhs-dmqrmzfz/hwz/sy/dmyw/content/post_2752267.html, 2021年6月30日最后访问。

[39] 《全市唯一! 江山市成功入选新一轮农村宅基地制度改革试点地区》,衢州传媒网, https://www.qz123.com/html/836/20201018/news_show_283688.html, 2021年6月30日最后访问。

[40] 《祝贺! 德清县入选新一轮农村宅基地制度改革试点地区》,搜狐网, https://www.sohu.com/a/424693163_99901975, 2021年6月30日最后访问。

[41] 《常州武进成为全国新一轮农村宅基地制度改革试点》,《常州日报》2020年11月5日, http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/628160453750191, 2021年6月30日最后访问。

[42] 《浏阳试点新一轮农村宅基地制度改革》,《浏阳日报》2021年1月21日, http://www.liuyang.gov.cn/lysz/zfg-zdt/zwdt/202101/t20210121_9742337.html, 2021年6月30日最后访问。

[43] 《全省5个, 全市唯一! 宜宾翠屏区启动农村宅基地制度改革试点工作》,宜宾市翠屏区人民政府网站, http://www.cuiiping.gov.cn/zwhd/cpyw/202103/t20210323_1437857.html, 2021年6月30日最后访问。

改革尚未完成,改革仍需深化。下一步的改革重点可以概括为以下方面:一是问题的多样性、需求的层次性,要求在新形势下调整改革重点,虑及新型城镇化与城乡融合发展、乡村振兴的要求;二是新情况、新问题的新应对,要求试点改革探索注意与新法衔接;三是改革的系统性、方案的体系融贯性,要求我们不能头痛医头、脚痛医脚,要注意规划上功能细分与弹性转化的平衡,并与宅基地有偿退出相协调。

打通宅基地与集体建设用地之间地性转换的通道,除了理论界和实务界共同关注的闲置宅基地向集体建设用地的地性转换外,还有本文论及的地性转换,即集体建设用地向宅基地的地性转换。在此过程中,需要明确农村宅基地与集体建设用地之间的划分标准和变更程序,^[44]同时避免地方通过种种“手段”将宅基地向集体建设用地单向转换损害农民利益。^[45]

四、地性转换的原则要求

“一切理论问题的研究,既要本于现实,同时最终也是为了解决现实中的问题”,^[46]要通过科学的制度设计回应和解决现实问题。宅基地是农民安身立命之所,是农村社会和谐稳定的保障。宅基地制度改革与农村产业发展、劳动力转移以及自然资源禀赋、乡村社会治理等密切相关,在农村土地制度改革中牵涉利益最为复杂,影响因素多元。^[47]“宅基地与集体经营性建设用地互转的条件、规模等也尚未构建完善机制。”^[48]包括地性转换在内的宅基地制度改革应坚持以下原则要求,为后续体系框架和制度设计提供指引。^[49]

(一) 坚持底线思维,依法规、合规划

坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线。一方面,要在坚持宅基地的集体所有制性质不改变的前提下,坚持规划引领,强化用地总规模控制和规划用途管控,避免以非法方式满足农民合法需求,确保耕地红线不突破。另一方面,要在有效保障农民生存发展的基础上探索户有所居的各种实现方式,注重宅基地“三权分置”改革与集体建设用地入市之间的统筹协调和相互衔接。^[50]

坚持规划引领,科学规划,优化布局。增强规划的民主性,完善土地规划编制程序,^[51]在摸清土地利用现状的基础上科学编制土地利用和村庄规划或制定实施细则,确保改革工作有序推进。一是科学修编村庄布局规划,开展“多规合一”的村庄发展一体化规划。二是加快村庄规划编制工作,充分尊重各村实际情况,要保持一定弹性,既避免千村一面,又有效回应

[44] 参见陈明:《提速农村宅基地改革,中央深改组又“安排”上了》,《新京报》2020年7月2日, <https://www.bjnews.com.cn/detail/159366881815767.html>, 2021年6月30日最后访问。

[45] 参见柳忠勤、党立倩:《空间规划治理与土地改革——访中国国土经济学会常务理事、中国科学院大学国家土地科学研究中心主任董祚继》,《今日国土》2020年第7期,第8页。

[46] 王家国:《马克思主义法学的实证化(代译序)》,载[奥]伦纳:《私法的制度及其社会功能》,王家国译,法律出版社2013年版,第26页以下。

[47] 参见乔金亮:《农村宅基地改革不能急躁冒进》,《经济日报》2020年10月15日第9版。

[48] 前引[4],袁威文。

[49] 或许有学者认为,通过土地利用规划、村庄规划等的调整即可实现地性转换所要达到的目的,不必如此大费周章。笔者认为,规划和地性转换是两项前后关联的制度,并非一回事,不能互相替代。

[50] 参见耿卓:《宅基地“三权分置”改革的基本遵循及其贯彻》,《法学杂志》2019年第4期,第39页以下。

[51] 参见李扬章:《试论土地利用总体规划编制程序的完善——提高程序的民主性》,《中国土地科学》2010年第12期,第28页以下。

现实需求。三是科学编制农村住房改造建设规划,按照村庄不同的定位和功能,规划不同的改造建设模式,合理安排建设时序,为地性转换划定边界。

坚持节约集约利用土地。农用地和建设用地是农村土地的基本分类,在土地总量不变的情况下,两者存在着此消彼长的关系。为了严格保护耕地,必须节约集约利用集体建设用地。具体而言,一是健全农村建设用地总量控制制度。通过调整土地利用总体规划,完善农村和社区空间布局规划,合理确定辖区集体建设用地总量。二是提高集体建设用地利用效率。为减少土地资源浪费、提高土地利用节约集约度,还可以考虑对地性转换设置前置程序,要求先对闲置宅基地进行整治。

(二) 坚持以人为本,确保农民户有所居

坚持以人为本,要求切实尊重农民意愿,维护农民合法权益,保障好农户宅基地分配的资格,确保农民的基本居住权利,使地性转换惠及广大无宅或失宅的村民。

为节约集约利用土地,有效保障农民住有所居,应在坚持“一户一宅”的同时更新观念,从宅基地制度实质保障农民居住的初衷出发,丰富住房保障的实现形式。根据不同村庄的实际情况,探索不同区域农民住房保障的实现形式,实现“一户一宅”向“户有所居、住有宜居”转变,可以沿用“一户一宅”政策、按户分配宅基地,也可以按人分配住宅、按户控制,还可以实行“一户一居”。^[52]为此,需要在以下方面着力:一是应制定集体成员资格认定的标准和条件,对“户”作出恰当界定;二是落实宅基地资格重新取得制度,赋予因自然灾害丧失宅基地使用权的农民和自愿将宅基地无偿退还集体的进城落户农民重新取得宅基地的权利;^[53]三是构建宅基地资格登记制度,登记信息主要包括集体成员身份,因分配取得的宅基地的四至、面积及方位,宅基地上构筑房屋及其他附属物的基本情况等。^[54]

宅基地资格在其中处于关键位置。“农户资格权本质上属于农民集体成员权的组成部分,是取得用益物权性质的宅基地使用权的基础。”^[55]从现有讨论和政策倾向来看,当下宅基地“三权分置”改革中的“资格权”保障主要是针对已分得宅基地的农民;而从农村现实来看,具有集体成员资格、符合申请宅基地条件但因无地可批而无宅基地的农民,则有意无意地被忽视。这种不平等与正义相悖。未来可以考虑适当放宽宅基地使用权原始取得的主体范围,也可以“探索新型农村村民住宅保障制度,从而实现基本人权价值、财产权利自由及效益的立法价值的统一”。^[56]

总之,立法设想最后是要变成人民的权利和义务的,因此我们还必须调查人民对我们建立的法律制度的法感情,运用科学的法技术,实现法律制度的科学性、体系性。^[57]

(三) 遵循实践逻辑,注重体系协调

1. 尊重基层实践

理论研究必须从实际出发,遵循实践逻辑,这也是马克思主义法学理论研究的基本方法论

[52] 参见向勇:《一户一居:中国农民住房保障补充规范》,《中国土地科学》2021年第1期,第34页。

[53] 参见前引[15],宋志红文,第84页。

[54] 参见程秀建:《宅基地资格权的权属定位与法律制度供给》,《政治与法律》2018年第8期,第39页以下;孙建伟:《宅基地“三权分置”中资格权、使用权定性辨析——兼与席志国副教授商榷》,《政治与法律》2019年第1期,第136页。

[55] 管洪彦:《宅基地“三权分置”的权利结构与立法表达》,《政法论丛》2021年第3期,第149页。

[56] 王崇敏:《宅基地使用权制度现代化构建》,法律出版社2016年版,第143页以下。

[57] 参见孙宪忠:《推进我国农村土地权利制度改革若干问题的思考》,《比较法研究》2018年第1期,第179页。

原则,具有“头等重要的位置”。^[58]顶层设计要以对基层实际的全面了解为前提。各地千差万别,只有提取出共同之处,才可能作出科学的顶层设计。同时,还应给地方留出实践探索试错的空间。要更加重视并积极总结农民的实践探索,同时鼓励并创造条件保障农民勇于先行先试,在符合国家和省市相关政策的前提下积极探索地性转换的有效路径。

面对突出的人地矛盾和耕地保护的硬约束,中央政策提出了任务目标,但并未限定实施路径和行动方案。因此,我们应在坚守底线原则的前提下,以保障户有所居为目标,处理好政策引导和村民自治的关系,将宏观政策引导与基层实践探索结合起来,^[59]充分考虑各区域经济社会发展状况和资源禀赋差异,探索形成适合不同村庄的地性转换路径和模式。例如,2019年修改的《汕头经济特区农村村民住宅建设管理办法》第6条首先区分了在城市(镇)规划区内外进行农村村民住宅建设的两类情形,然后又根据是否使用原有宅基地规定了不同的建设主体,为利用集体建设用地建设农民公寓满足农民居住需求提供了基本依据,发挥了市场优势,保障了集体经济持续发展。

当然,地性转换只是为农民住有所居提供一种可供选择的途径,并非也无法强制推广,因此应允许农民集体结合本地实际情况作出不同选择,如通过集体经营性建设用地入市的增值收益补偿无地农民。

2. 注重改革协同

制度之间具有系统性、整体性、协同性、互补性,任何单一制度都不能单独发挥作用。地性转换的关键是在遵循宅基地制度变迁内在逻辑的基础上,实现内部的体系化及其与外部关联的体系化。既要考虑宅基地内部“三权分置”改革的系统性方案,也要与其他“两块地”改革、要素市场化配置、乡村振兴战略实施、新型城镇化推进、城乡融合发展等一起,在整个社会系统中作体系化思考。

为配合宅基地“三权分置”改革,实现相关政策的协同联动,增强改革的系统性,根据中共中央、国务院《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,应改革宅基地的分配方式,实行宅基地有偿使用制度。地性转换关系到农民户有所居的实现,必然以宅基地“三权分置”的资格权为前提和依凭,因此应确保对农民的全覆盖,尤其应对无宅基地农民的宅基地资格权予以确权和保护。

坚持把地性转换放在乡村振兴和城乡融合的大局中考虑,优先着力破解阻碍乡村内部要素自由流动的体制机制性障碍,在保障居住生存与经济发展之间寻求平衡。除了与中央层面的改革政策相协调外,地性转换改革政策也要兼顾地方的改革探索。例如,广东的“旧城镇、旧厂房、旧村庄”(“三旧”)改造中的旧村庄改造主要在于宅基地整治,通过宅基地整治形成的集体建设用地,可以成为地性转换中集体建设用地的来源。因此,在推行地性转换时可参考借鉴“三旧”改造中的经验做法。

五、地性转换的制度要点

任何社会活动都是在一定的制度环境中进行的。既有的制度环境蕴含了社会活动所依凭的

[58] 参见张文显主编:《马克思主义法理学:理论、方法与前沿》,高等教育出版社2003年版,第51页。

[59] 参见前引〔4〕,袁威文。

基本制度资源,规定了目标方向和约束条件。从规范基础来看,地性转换可以依凭的制度规范主要有民法典第364条和土地管理法第62条第1款以及《土地管理法实施条例》,^[60]特别是乡村振兴促进法第67条第1款。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出的目标,即“闲置宅基地、废弃的集体公益性建设用地转变为集体经营性建设用地入市”、“不同产业用地类型合理转换机制”和“让全体人民住有所居”,^[61]为地性转换的实施提供了指引。

集体建设用地向宅基地的地性转换与公司法上的组织类型转换在逻辑上有一定的相似之处,均为“一种十分封闭的立法结构”,因此应坚持“融通主义”改革观,^[62]为地性转换提供自由空间。运用法律关系原理,遵循权利构造逻辑,我们可以把主体、客体、过程以及外部的政府角色作为地性转换制度体系的“四梁八柱”,搭起制度的基本框架。

(一) 决定的主体

地性转换指向农民个体的居住需求,因此农民个体即农民或农民集体成员是基本的主体力量,是制度体系的中心。农民个体无法从农民集体直接获得宅基地时,才会产生该需求,因此无论是从农民所处的集体还是从农民需求满足的角度看,农民集体都有其基础性地位。农民集体对其所有土地的开发建设是所有权的直接行使,地性转换只是具体利用方式的变换,并无第三人的存在。而在农民集体为他人设立有集体建设用地使用权时,地性转换就必然涉及其他权利人。根据土地管理法第66条第3款的规定,因地性转换需要收回集体经营性建设用地使用权的,只能通过双方事前签订书面合同或事后协商解决。这些主体都是地性转换法律关系中平等的当事人。此外,还有始终存在的作为行政监管主体、规划管控主体的政府机关。其中,农民集体是主轴,关系到对集体所有制的坚持和完善,需要具体制度设计和配套保障措施,如农民集体经济组织的内部治理和运作机制、集体土地所有权权能充实以及集体成员与农民集体之间关系的理顺。

决定的主体是地性转换的发动者、推动者、行动者,需要划定主体范围、厘清主体权责。决定地性转换事项的主体只应是农民集体;在没有建立集体经济组织的农村,则应由村民自治组织即村民(代表)大会或由其选举产生的村民委员会依法决定。农民集体或村民委员会既要有决策的资格和权利,又要具备作出决策的条件和基础。对于农民集体,根据民法典第260条至第263条的规定,本集体成员集体是所有权主体,集体经济组织或村民委员会代表所有权主体行使所有权。对于村民委员会,可依循村民委员会组织法运行;但集体经济组织的身份未明,只是可以取得法律尚付阙如的特别法人资格。笔者以为,除了具备资格,还要享有相应的权利,这对主体虚化弱化、权能不完整不充分的集体土地所有权来说,尤为重要。

[60] 国务院2021年7月2日发布的《土地管理法实施条例》专节规定了宅基地管理和集体经营性建设用地管理,不过并未具体涉及本文讨论的主题,只有其第33条第1款第2句把土地管理法第62条第2款具体化为“县级以上地方人民政府应当按照国家规定安排建设用地指标,合理保障本行政区域农村村民宅基地需求”。不过,这一规定仍停留在指引层面,难以直接发挥规范作用。

[61] 虽然这一目标是在第29章“全面提升城市品质”中提出的,但显然具有普适性;而且住房保障对象也覆盖到了进城落户农民。

[62] 参见蒋大兴:《论公司/组织法上的类型转换》,《法学评论》2021年第3期,第56页以下。“封闭的立法结构”是指立法者出于一种形式化、表面化的立场,过于强调不同类型之间的差别,认为非此即彼,在制度设计上注重对他们的隔离,而对背后的内在关联和互动关系关注不够。

（二）决定的内容

集体所有权必须由农民集体成员进行民主管理并依照法定程序进行，这是其在内容上的重要法律特点。^[63]从地性转换的要素和过程来看，集体决定的内容大致可以分为以下几项：（1）可否开展地性转换。该项内容的决定需要考虑不同集体建设用地的具体用途、位置、面积以及无宅基地村民的实际情况、主观意愿等因素。（2）地性转换的客体 and 对象。向宅基地转换的集体建设用地，既可以是集体经营性建设用地，也可以是集体公益性建设用地。从实践来看，还必须考虑地性转换的可能性和可行性。从可能性看，集体建设用地的权属应当清晰明确，不存在争议。鉴于地性转换后成为村民居住的住宅用地，集体建设用地应具备必要的基本公共设施，如交通、水电气等。从可行性看，集体建设用地处于低效利用甚至闲置状态时，才最有可能转换为宅基地，就集体公益性建设用地而言也是如此。（3）地性转换后宅基地形态的选择，即是选择传统“一户一宅”还是选择农民公寓等形式。根据原国土资源部《关于进一步完善农村宅基地管理制度切实维护农民权益的通知》（国土资发〔2010〕28号）的要求，土地利用总体规划确定的城镇建设扩展边界外的村庄，要严格执行一户只能申请一处符合规定面积标准的宅基地的政策；土地利用总体规划确定的城镇建设扩展边界内的城郊、近郊农村居民点用地，原则上不应再进行单宗分散的宅基地分配。（4）地性转换后如何分配。地性转换后形成的宅基地以及由此产生的集体建设用地收益如何分配，是整个决定中的核心问题。有权获得宅基地的农民仍须符合“一户一宅”之要求，可以根据有无宅基地、宅基地面积是否达标、申请时间等因素确定先后顺序。

地性转换尽管有其特殊性和独立性，但也只是宅基地制度和集体建设用地制度的组成部分，可以在没有规定或规定不明时参照适用相关制度。从构成和过程来看，有集体建设用地功能用途的地性转换，也有宅基地的取得与分配。对于后者来说，由地性转换而来的宅基地的分配和常规的宅基地初始取得制度并没有什么不同，自然可以参照适用。对于前者来说，情况则有些特殊，有入市本身和入市后的不同。入市后，只要符合国土空间规划，无论用于工业还是用于商业，集体都可以自由自主决定，法律没有专门规定。集体经营性建设用地入市本身是农村土地制度改革的重大成果，主张集体经营性建设用地可用于住宅开发的改革设想，^[64]对构建地性转换制度颇有启发性，可以统筹考虑。

（三）决定的程序

决定关涉各方利益，只有周密的程序才能保障地性转换的顺利实现。这就要求地性转换的程序必须能充分反映相关当事人的意志，必须保障当事人有效实质参与，必须完整、合理、可控。地性转换涉及农民集体权益的重新分配，关系到无宅基地农民的住有所居，总会存在不同甚至截然对立的意见，因此要从决定过程的制度条件、目的、角色作用、功能等的整合与效率以及理由的充分性等方面来把握程序的合理性，进而充分发挥程序所具有的限制恣意、保证理性选择和反思性整合等功能，^[65]吸收异议，平衡利益，凝聚共识，实现预期目标。

[63] 参见王利明：《物权法研究》上卷，中国人民大学出版社2007年版，第534页。

[64] 参见宋志红：《集体建设用地使用权设立的难点问题探讨——兼析〈民法典〉和〈土地管理法〉有关规则的理解与适用》，《中外法学》2020年第4期，第1059页以下。

[65] 参见季卫东：《法律程序的意义——对中国法制建设的另一种思考》，《中国社会科学》1993年第1期，第87页以下。

不过,地性转换的程序不宜简单参考、类比集体经营性建设用地入市程序进行设计,应基于宅基地的保障福利性质,考虑比照宅基地申请审批的程序进行。“为了更好地平衡国家、集体和个人之间的利益冲突,保护农户基于生存保障需要而平等享有的对集体土地的权益,在尊重集体土地所有者自主支配权的前提下,政府应当通过立法或者行政政策……适当干预。”〔66〕有关部门可以结合基层治理、民主管理,制定示范章程、实施细则以供参考。笔者以前曾主张,是否转换、转换多少、怎么转换等决定权,都可依法交给集体。〔67〕现在看来,这一说法虽意在维护农民集体的主体地位,但失之于简单,对集体建设用地向宅基地的地性转换与宅基地向集体建设用地的地性转换的性质、特点等认识得不够深入细致,对不同群体农民的不同诉求考虑不够,因而可行性不强,不应再坚持。

鉴于集体土地上建租赁住房改革与地性转换的相关性和协同性,在实施地性转换时可以搭前者的“顺风车”,立法还可以通过放开入市集体建设用地不得用于住宅开发的限制,通过与国有建设用地的“同地同权”实现地性转换的目标。在改革无法一步到位的情况下,国家也可以把地性转换作为“同地同权”先行先试的内容,在东南沿海经济发达的地区,以地级市为单位,选择若干县级地区开展试点,提炼具体条件、过程管理等经验,然后总结复制推广。

地性转换实现路径的设计必须察明这些要素并在选择时仔细斟酌,才可能达成预期目标。即便如此,地性转换作为制度构想要作用于现实,最终变成现实,还有很长的路要走,需要继续在既定的制度环境下接受实践的检验和修正。

结语:地性转换的现实制约与制度前景

“农民集体财产的分配正义是农民集体成员权行使的重要价值目标”,包括宅基地使用权在内的用益物权,是农民集体成员理应享有的主要权利。〔68〕地性转换为失去和未分得宅基地的农民提供了基本居住保障,保证其“有得住”,而且还为他们“住得好”提供了制度支撑。地性转换的实质就是对农民的赋权和还权,就是对农民自主选择和安排的尊重,就是承认农民的主体地位并助力其实现。不仅如此,地性转换还可以为闲置宅基地整治、集体经营性建设用地入市和农业产业化、农村现代化发展乃至助推中国农民参与城市化进程创造条件。〔69〕

不过,从学理和逻辑来看,地性转换是以人地关系紧张、经济发展与土地使用矛盾突出为前提的,虽然有其普适性,但并非放之四海而皆准,还会受到社会现实客观条件的制约。地性转换根本上取决于当地的集体建设用地情况,农民集体的组织能力和无宅基地农民的需求也是关键影响因素。不仅如此,满足无宅和失宅农民居住需求的途径是多元的,〔70〕地性转换只是其中的一种可能路径、一种尝试探索的方案,必须正视其在适用范围和功能作用上的可能限度。具体而言,地性转换的适用受到以下限制:一是集体建设用地存量规模及利用情况;二是

〔66〕 前引〔21〕,陈菲菲等文,第155页。

〔67〕 参见前引〔50〕,耿卓文,第39页以下。

〔68〕 王雷:《农民集体成员权、农民集体决议与乡村治理体系的健全》,《中国法学》2019年第2期,第146页。

〔69〕 参见刘守英:《集体土地资本化与农村城市化——北京市郑各庄村调查》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2008年第6期,第130页。

〔70〕 有学者依据《土地管理法》第62条的规定,将居住权适用于宅基地以解决农村宅基地闲置和经济利用需求的问题。参见李永军:《论我国民法典上用益物权的内涵与外延》,《清华法学》2020年第3期,第88页。

农民集体经济实力及发展状况，这既关系到财力保障，又与集体经济组织的领导组织能力密切相关；三是农村基层治理状况、集体经济组织治理方式和水平。

总之，地性转换这一看似不起眼的改革方案并非像表面那样简单容易，尤其是有宅基地农民与无宅基地农民之间的利益平衡在集体决议机制中如何实现，必将成为一道难题。而宅基地制度改革和集体经营性建设用地入市所面临的问题显然也会在地性转换中表现出来。地性转换的顺利实现和有序运行也离不开制度保障：村庄规划、国土空间规划与耕地保护审批流程是地性转换的制度前提；土地整治与指标归属和使用的制度规范是地性转换的制度核心；确权登记与历史遗留问题解决是地性转换的制度支撑；行政体制的调整如自然资源主管部门与农业农村主管部门的协调衔接是地性转换的制度关键。地性转换也离不开政府的协力，政府应坚持农业农村优先发展理念，在国土空间规划和建设用地指标上予以倾斜。^[71]

Abstract: The legal requirements and practical needs put forward the reform proposition of the transformation between homestead land and collectively-owned construction land, which is of great policy value and practical significance. The transformation has its ethical and historical basis, and the basis and structure of right has laid the institutional foundation for transformation. From the perspective of practical development, the transformation has the characteristics of indirectness, fuzziness and informality and can be divided into self-acting stage, strict-control stage, “three kinds of land” reform stage and a new round of reform stage. It contains institutional resources worthy of mining and utilization and capable of providing inspiration and reference for future development. To realize the transformation, we should adhere to the bottom line thinking, be people-oriented, ensure the economical and intensive use of collective construction land, respect grass-roots practice, highlight classified measures, pay attention to reform coordination, and clarify the main points of the system in terms of the subject, content and procedure of the transformation decision, so as to provide a theoretical scheme for realizing the reform goal of guaranteeing residence for each family of rural villagers.

Key Words: Land Administration Law, guaranteeing residence for each family, homestead land, collectively-owned construction land, transformation of land nature

[71] 由于国家规定农村土地归集体所有而非个人所有的目的是为了让个人不受别人的剥削，国家基于政府监护人理论，就必须对集体进行一定程度的制约，即在通过集体内部的民主机制保护个人权益的同时，还要通过国家机关的外部监督防止集体内部多数民主的“暴政”，避免村民个人权益遭受侵害。